

1501161-89.2021.8.26.0048

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, 29 porções de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, na data supra, o réu e seu comparsa traziam consigo as referidas porções de entorpecentes, para fins de tráfico, no local acima indicado, que é amplamente conhecido como ponto deste comércio espúrio, quando foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501161-89.2021.8.26.0048 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501161-89.2021.8.26.0048

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON PAULO DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

EDSON PAULO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 30 de maio de 2021, na vigência de Estado de Calamidade Pública em razão da pandemia Covid-19, por volta das 13 horas e 50 minutos, na Rua Brincos de Princesa, 1, Prédios Coloridos, Caetetuba, nesta cidade e Comarca de Atibaia, agindo em concurso de agentes com outro indivíduo apenas conhecido como "BRUNO" ou "BRUNINHO", trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, 29 porções de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo foi apurado, na data supra, o réu e seu comparsa traziam consigo as referidas porções de entorpecentes, para fins de tráfico, no local acima indicado, que é amplamente conhecido como ponto deste comércio espúrio, quando foram avistados por guardas que passavam pela região.

Com efeito, tão logo perceberam a presença dos agentes de segurança, o réu e seu assecla saíram correndo. Aquele, porém, foi detido pelos guardas, enquanto o segundo conseguiu se evadir, dispensando, durante a escapada, uma sacola.

Ato contínuo, os milicianos revistaram o réu e encontraram consigo duas porções de

maconha e a quantia de R\$ 463,00, em notas trocadas. Ademais, recuperaram a sacola dispensada pelo comparsa e nela acharam outras 27 porções idênticas da mesma droga. Na ocasião e posteriormente na delegacia, EDSO alegou ser mero usuário e que o outro indivíduo (que fugira) – conhecido como BRUNINHO – era o verdadeiro traficante; que correu por já ter passagens; e que a quantia achada consigo era proveniente de seu trabalho como ajudante de pedreiro. Desta forma, inicialmente, o réu foi liberado.

Na sequência, a d. Autoridade Policial diligenciou no sentido de localizar e identificar “BRUNINHO” e, assim, precedeu à oitiva de Bruno Lima da Silva, morador do apartamento 33, bloco 3, nos “Prédios Coloridos”. Este, em síntese, negou qualquer envolvimento com tráfico e, realizada pesquisas de praxe sobre antecedentes criminais em seu nome, nada de relevante foi evidenciado.

Nada obstante e dando continuidade à investigação, a Autoridade Policial expediu nova intimação ao réu, para que este fizesse o reconhecimento de BRUNO. No entanto, EDSO não foi localizado no endereço em que informou residir, não sendo pessoa conhecida pela moradora. Destarte, fica claro que ele mentiu, a fim de não ser responsabilizado pela prática do crime em análise.

O réu foi notificado (fls. 97) e apresentou defesa prévia (fls. 104/108), que foi afastada, sendo recebida a denúncia (fls. 112/115).

O réu foi citado por precatória (fls. 145/152).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns (fls. 142/143), sendo o réu interrogado ao final (fls. 180).

Em memoriais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal porque provados os fatos narrados na denúncia (fls. 184/189).

A defesa requereu a improcedência da ação, com a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando, em síntese, que a prova é insuficiente para a demonstração do crime de tráfico de drogas, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, ou, ainda, a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, alegando que o réu trazia consigo duas porções de maconha, que se destinavam a consumo pessoal; subsidiariamente, em caso de condenação, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal, com fixação do regime menos gravoso, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o direito de apelar em liberdade (fls. 210/225).

É o relatório.

Passo a decidir.

A ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 03/05), no auto de exibição/apreensão (fls. 09/10), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 11), nas fotografias (fls. 12/13), no laudo toxicológico (fls. 34/36), e na prova oral produzida.

A autoria criminosa deve ser imputada ao réu que, interrogado extrajudicialmente, disse que na ocasião dos fatos estava na Rua Brinco de Princesa, local onde mora, quando se dirigiu até o prédio verde para comprar duas porções de maconha; a guarda municipal chegou no momento em que o rapaz estava vendendo e saíram correndo para evitar a abordagem; correu porque já teve duas passagens por tráfico; o rapaz que vendeu a droga correu e dispensou a sacola no caminho; o rapaz conseguiu fugir, sendo que não sabe dizer o nome dele, somente o conhece pelo prenome Bruninho; foi pego pela guarda e, consigo, foram encontradas somente as duas porções de maconha para seu consumo e a quantia de R\$ 463,00 reais; o dinheiro encontrado consigo é referente ao seu pagamento quinzenal de seu trabalho como servente de pedreiro; ganha R\$ 80,00 por dia e R\$ 800,00 reais por quinzena (fls. 08).

Em juízo, interrogado às fls. 180, o réu negou os fatos. Questionado por que acha que está sendo acusado, disse que porque foram encontradas consigo duas porções de maconha; questionado por que correu quando a polícia apareceu, disse que chegaram muitos policiais atirando, e havia muitas pessoas no local; questionado por que está dizendo isso, sendo que na Delegacia não falou nada sobre terem atirado, disse que correu pois tem “passagem”, e tinha medo de ser preso por drogas que não eram suas; questionado por que correu, se não estava com a droga, disse que estava com apenas duas porções; questionado por que suas porções eram exatamente iguais às que

foram encontradas com a pessoa que estava consigo, e que também correu, disse que estava comprando no momento da abordagem; questionado de onde eram os R\$ 463,00, disse que do seu trabalho como servente de pedreiro, sendo que estava com o dinheiro porque tinha acabado de receber; questionado como tinha acabado de receber, se o dia 30 de maio era um domingo, disse que trabalha com seu tio, tinha acabado de receber, e quando foi comprar a droga, houve a abordagem; questionado se recebeu todo esse dinheiro e, em vez de guardá-lo na sua casa, saiu para passear com o dinheiro, disse que saiu no fim de semana; questionado por que o dinheiro estava todo trocado, disse que não estava; às reperguntas da defesa, questionado por que informou o endereço da Rua Brincos de Princesa, 365, Bloco 2, apartamento 22, se não morava lá, disse que no dia da abordagem, estava no Bloco 2, onde mora seu tio Vicente, tanto que ele o acompanhou até a Delegacia na data dos fatos; questionado pelo juízo sobre a polícia ter tentado localizá-lo nesse endereço, que supostamente é do seu tio, mas terem recebido a informação de que não o conheciam, disse que quem respondeu os policiais foi a mulher do seu tio, que é deficiente; questionado se ela não sabe quem é, disse que não sabe porque ela fez isso; questionado pela defesa qual a deficiência da sua tia, disse que ela é muda; trabalha como motoboy, e ganha R\$ 4,00 por cada entrega, totalizando cerca de R\$ 1.400,00 por mês; estudou até a oitava série; já foi processado e preso por tráfico.

A testemunha Junior Fernandes de Santana, guarda municipal, ouvida às fls. 142/143, disse que, na data dos fatos, estava em patrulhamento, juntamente com a equipe e outra viatura, na região dos "prédios coloridos", local já conhecido nos meios policiais como ponto da traficância, quando foram avistados dois indivíduos que, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga a pé, tendo seu companheiro de equipe logrado êxito em alcançar um deles, enquanto o outro conseguiu fugir, dispensando, durante a fuga, uma sacola plástica, contendo 27 porções de maconha; com o réu, foram encontradas duas porções de maconha idênticas às que estavam na referida sacola, mais a quantia de R\$ 463,00; o réu, indagado, alegou que era usuário, e que estava comprando a droga do outro indivíduo que conseguiu empreender fuga; EDSO alegou, ainda, que empreendeu fuga pois já tinha passagem criminal por tráfico de drogas, e que o dinheiro era oriundo do seu trabalho; o dinheiro estava dividido em notas grandes e notas trocadas; às reperguntas da defesa, questionado se houve alguma denúncia com relação ao réu, disse que não; questionado se foi feita alguma busca na residência do réu, disse que não; questionado se foi encontrada, com o réu, alguma anotação relacionada ao tráfico, disse que não, somente as duas porções de maconha e o dinheiro.

A testemunha Leandro Sanches Bueno, guarda municipal, ouvida às fls. 142/143, disse que na data dos fatos, a equipe estava em patrulhamento na região do bairro Caetetuba, próximo aos "prédios coloridos", região bastante conhecida pelo tráfico de drogas; em dado momento, foram avistados dois indivíduos em atitude suspeita, que se evadiram quando foi feita a tentativa de abordagem, sendo que apenas o réu foi alcançado pela equipe; em busca pessoal, foram encontradas duas porções de maconha com o réu, além de R\$ 463,00, ocasião em que EDSO negou o tráfico, alegando que estava comprando a droga para consumo próprio; ambos os indivíduos, o réu e seu comparsa, empreenderam fuga quando a viatura se aproximou, sendo que o outro indivíduo dispensou, durante a fuga, uma sacola, contendo algumas porções de entorpecentes; o dinheiro encontrado com o réu estava trocado; às reperguntas da defesa, questionado se foi encontrada, com o réu, alguma anotação do tráfico ou embalagens de drogas, disse que não, apenas as duas porções de droga e a quantia em dinheiro trocado.

Assim, os fatos estão plenamente comprovados.

O réu, em fase policial, negou o tráfico, alegando que estava apenas comprando a droga para consumo próprio, quando foi abordado pelos guardas. Em juízo, interrogado, voltou a negar os fatos, alegando que levava consigo apenas duas porções de maconha, que se destinavam a consumo pessoal, e que correu porque os policiais chegaram atirando, e por ter antecedentes. Disse, também, que os R\$ 463,00 eram provenientes do seu trabalho, valor que foi pago pelo seu tio, com quem trabalhava como servente de pedreiro.

No entanto, sua negativa foi infirmada pelas demais provas produzidas, restando claro o objetivo de se eximir da responsabilidade pelos fatos criminosos. Senão, vejamos.

Os guardas municipais narraram que estavam em patrulhamento pela região dos "prédios coloridos", local conhecido como ponto da traficância, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, que empreenderam fuga ao visualizarem a viatura. Disseram, também, que um dos indivíduos logrou êxito em fugir, dispensando, durante a fuga, uma sacola contendo 27 porções de maconha, tendo o réu sido preso, ocasião em que foram encontradas, com ele, duas porções de maconha idênticas às que estavam na referida sacola, além de R\$ 463,00 em notas trocadas. Narraram, ainda, que o réu, indagado, negou o tráfico, alegando que estava apenas comprando os entorpecentes para consumo próprio, e que tentou fugir porque tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Conveniente rememorar que os depoimentos judiciais de guardas municipais e policiais, sejam civis ou militares, têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo descabido eventual preconceito acerca de seus testemunhos.

Inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por guardas municipais ou policiais, sejam civis ou militares, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Inexiste, ainda, qualquer impedimento ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em princípio, depoimentos provenientes de guardas municipais e policiais, civis ou militares, sendo institucional qualquer entendimento que retire valor, a priori, dos depoimentos dos agentes da Lei, pelo simples fato de emanarem de pessoas revestidas de tal qualidade.

Neste sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Por isso, os depoimentos dos agentes da Lei ouvidos merecem total credibilidade e servem perfeitamente como supedâneo para prolação de sentença condenatória, guardas municipais que não tinham, mesmo, qualquer interesse maior da gratuita acusação do réu.

Assim, ao contrário do que alegou a defesa, em seus memoriais, verifica-se que o réu estava, mesmo, na traficância, já que foi abordado em região amplamente conhecida como ponto do tráfico, ocasião em que levava consigo drogas idênticas às outras 27 porções de maconha dispensadas pelo seu comparsa, durante a fuga, além de R\$ 463,00, cuja origem lícita não foi comprovada por qualquer meio. Aliás, embora tenha alegado que o dinheiro era fruto do seu trabalho, não trouxe aos autos nada que pudesse comprovar sua versão, não tendo sequer arrolado como testemunha o tal tio, que supostamente fez o pagamento em pleno domingo, logicamente porque não é verdade, sendo evidente que o valor em questão era proveniente do tráfico de entorpecentes.

E, não por acaso, o réu é duplamente reincidente específico, já que, conforme se verifica às fls. 70/71, ostenta duas condenações também por tráfico de drogas, já transitadas em julgado, não havendo qualquer dúvida de que está intimamente envolvido com tal atividade espúria, tanto é que fugiu ao avistar os agentes da lei, logicamente porque estava delinquindo.

Verifica-se, portanto, que a versão do réu, além de inconsistente (tanto é que, em

juízo, narrou que correu porque os policiais chegaram atirando, o que não mencionou em solo policial e, logo em seguida, disse que correu pois tinha antecedentes), é absolutamente fantasiosa, e restou isolada nos autos, tendo o robusto conjunto probatório trazido aos autos sido plenamente apto a comprovar que o réu efetivamente praticou o crime pelo qual foi denunciado, razão pela qual a condenação é medida que se impõe.

O pleito da defesa de desclassificação do tráfico para o delito de uso de drogas não pode ser acolhido, isto porque, a negativa, por si só, é irrelevante e comum ao tráfico.

Neste sentido:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

Por fim, observo que o tipo do art. 33 não faz menção a 'uso próprio'. Tal menção é feita no art. 28, ambos da Lei 11.343/06. Destarte, se o réu acusado de tráfico pretende que se aceite que a posse da droga era para uso próprio, com desclassificação para o art. 28, e consequente desfazimento da presunção de que se trata de traficante, terá que provar a alegada destinação. E esta prova cabe à defesa, não à acusação. Na hipótese, tal prova não foi feita, estando devidamente comprovado, conforme já fundamentado, que o réu estava na traficância.

Outrossim, ainda que o réu seja usuário, isto, por si só, não afasta o tráfico, sendo comum o usuário se tornar traficante por não ter condições financeiras de manter seu vício.

Assim, uma vez que os argumentos apresentados pela defesa não foram capazes de sustentar a negativa do réu, que restou isolada no processo, ante o arcabouço probatório analisado, não há que se falar em desclassificação, muito menos em absolvição.

Assim, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59 do Código Penal. No entanto, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O réu é duplamente reincidente específico, conforme se verifica às fls. 70/71.

Considerarei como Maus Antecedentes o proc. 104-84.2015 (fls. 70 - tráfico), sendo a outra reincidência considerada como agravante.

Não há que se falar em bis in idem na consideração da reincidência e dos Maus Antecedentes, porque como já se decidiu, se o réu for duplamente reincidente, uma das circunstâncias pode ser considerada como agravante e a outra, como circunstância judicial para aumento da pena-base (TACRIM, ACrim 455.109, 8ª Câmara, em 18-12-99, rel. Silva Pinto).

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO ANTERIOR À ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. MESMA CIRCUNSTÂNCIA DE AGRAVAMENTO DE PENA CONSIDERADA DUAS VEZES. FASES DISTINTAS DE APLICAÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. JUÍZO NEGATIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ. QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. (...) 4. É pacífica a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação da pena-base acima do patamar mínimo. 5. Este Sodalício orienta que não configura bis in idem ou inconstitucionalidade, quando, reconhecidas múltiplas reincidências, o sopesamento, na fixação da condenação, de uma na primeira fase, para exasperar a pena-base pelos Maus Antecedentes (art. 59,

CP), e de outra na segunda fase, como circunstância agravante (art. 63,CP) (...)" (STJ - HC: 215126 MS 2011/0183443-9, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 18/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2013) (destaquei).

Culpabilidade normal à espécie. Não há informações sobre sua conduta social ou personalidade, motivo pelo qual deixo de valorá-las. Quanto aos motivos do crime, nada capaz de ensejar modificação de pena. As consequências do crime são as normais ao tráfico. Não há que se falar em comportamento de vítimas. Quanto à natureza e quantidade do produto, nada a considerar.

Assim, em razão dos maus antecedentes, a pena do réu é fixada acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Quanto ao valor da diária, deverá ser fixado acima do mínimo, já que o réu noticiou, em seu interrogatório, que tem renda mensal de R\$ 1.400,00. Assim, levando-se em conta que o valor da diária deve corresponder a 1/30 avos dos rendimentos do réu, o valor deve ser fixado em R\$ 46,00, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Na segunda fase de dosimetria, há a agravante do artigo 61, II, j, do Código Penal, posto que o crime foi praticado durante estado de calamidade, decretado em março de 2020, em razão da pandemia covid-19, bem como a agravante relativa à reincidência, conforme se verifica às fls. 71 (proc. 3000102-70.2013 - tráfico), não havendo atenuantes.

Assim, agravo a pena do réu, que passa a 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias-multa, diária de R\$ 46,00.

Na última fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Afasto a incidência do benefício do parágrafo 4º, porque o réu é duplamente reincidente específico, não preenchendo, portanto, os requisitos legais. Ademais, não obstante já ter sido condenado duas vezes por tráfico, segue na mesma atividade espúria, o que demonstra seu profundo envolvimento com o meio delitivo.

Incabível, também, a substituição do art. 44, bem como a suspensão do art. 77, ambos do Código Penal, porque, conforme já exposto, se trata de réu duplamente reincidente específico, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para a concessão dos benefícios.

O regime inicial para cumprimento da pena será o fechado.

O tráfico de entorpecentes é das atividades mais danosas ante o seio social hodierno. Sua prática atinge diretamente direitos e garantias fundamentais das pessoas, além de fomentar outros tipos de atividades ilícitas. Causa, ainda, direta e indiretamente, considerável mobilização estatal, atingindo, por consequência, o erário público, que tem de arcar com as custas de policiamento ostensivo, seja preventivo ou repressivo, campanhas de conscientização - sobre o óbvio, diga-se -, tratamento de saúde aos adeptos do uso contumaz, dentre outras inúmeras situações relacionadas, as quais requerem pronta ação do Estado. Isto, entretanto, custa dinheiro e onera o contribuinte.

Seria um contrassenso o mesmo Estado que luta para combater tão nefasta prática - a tão altos custos - permitir que seu principal responsável retorne à liberdade sem experimentar a necessária punição e, principalmente, sem que de seu ato se arrependa, sobre ele reflita e o corrija, podendo criar, em última análise, a aplicação de regime mais brando, verdadeira sensação de impunidade, capaz, inclusive, de ensejar ao condenado mais um motivo para que torne à rentável prática.

Nem se diga haver o pequeno traficante, sobre quem recairia todo o peso da mão Estatal, e o grande traficante, que se ocultaria na hierarquia da coalizão narcotraficante, como tentativa de justificar atos injustificáveis. A Lei coíbe o tráfico e este existe por duas razões: porque alguém consome o produto final e, principalmente, porque alguém o vende - eis a figura daquele que trafica, independentemente de sua posição hierárquica.

A ação do indivíduo encarregado de disseminar a substância entorpecente - geralmente identificado como o "pequeno traficante" - deve ser entendida como parte integrante e crucial do conjunto responsável pela narcotraficância: é ele que, por meio de sua ação, viabiliza o comércio "varejista" das drogas, fomentando o consumo

e a própria continuidade da produção de entorpecentes, consubstanciando, sua atividade, não só o meio de sustento próprio, mas de toda a cadeia criminoso ligada ao narcotráfico – prática delitativa que domina a maior parte dos debates sobre segurança pública e que consiste, em verdade, no cerne financeiro das atividades criminosas em geral.

É do espírito da Lei combater o tráfico ilícito de entorpecentes, seja ele praticado pelo iniciante – a quem é conferido algum tipo de benefício, conforme se observa do parágrafo 4º do artigo 33, Lei 11.343/06 – pelo gerente de “boca” ou por associados a organizações criminosas – pessoas a quem a Lei trata de maneira especial e mais severa.

O fato é que o tráfico, independentemente do tipo de atuação de seu praticante, merece reprimenda exemplar.

Sobre todo o tema até então debatido, uma brilhante manifestação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“(…) Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e a recente decisão da Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo entendimento. Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de direitos” constantes dos artigos 33, § 4º e 44 da Lei Antidrogas. Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia, não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos. Na decisão é ressaltada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição. Tal como veiculado de forma contínua nos diários de grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades, inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação. Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal. Evidentemente o grande traficante, o responsável pela distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de necessidades básicas. Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. O número expressivo de pessoas que poderiam ser servidas com as drogas, bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena por quaisquer das medidas alternativas. Portanto, acolho a pretensão do representante do Ministério Público e fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista que se trata do regime compatível com a conduta do acusado. Cumpre ressaltar ainda que as circunstâncias dos autos, a meu sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se tratava de pequenos traficantes, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada por um revés de complexidade. Qual a equação para se distinguir o grande traficante do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão? A constância da atividade do comércio ilegal? Cabe aqui outra indagação: não parece pouco provável que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante? A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de pequeno traficante, estar-se-á

procurando combater sempre o efeito e não a causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do pequeno traficante. Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator, beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas. E a consequência desta fartura financeira é previsível, ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua sobrevivência. Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano. Devo reconhecer que tenho sido voto vencido junto a meus pares, a cujos posicionamentos me curvo com a humildade esperada, e por isso mesmo, eventualmente, sou reconhecido como extremamente rigoroso, entretanto, não o faço como castigo, o que seria de todo despropositado e bem acarretaria o desvirtuamento da finalidade da pena. É imperativo ressaltar também que não tenho a menor intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes - como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na Lei nº 11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria visualizar a figura do pequeno traficante. (...)” (APL TJ-SP 0027320-18.2012.8.26.0224; Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal Extraordinária; Publicação: 18/01/2017; Julgamento: 14 de Dezembro de 2016; Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro).

Salutar a fundamentação, que reduz a termo o espírito buscado pela construção normativa do Legislador. É razão mais que suficiente para que se entenda que o praticante do tráfico de drogas deve permanecer afastado do convívio em sociedade, especialmente considerando, repito, que se trata de réu duplamente reincidente específico.

Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno EDSON PAULO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e multa de 777 dias-multa, diária de R\$ 46,00, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

O réu não respondeu ao presente processo em cárcere. Uma vez ausentes os pressupostos ensejadores de sua custódia cautelar, poderá apelar em liberdade. Transitada esta sentença em julgado, comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, expedindo-se mandado de prisão em regime fechado.

Condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea “a” da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003. Suspensa, entretanto, a condenação, caso o réu seja beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

P.R.I. e C.

Atibaia, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA